Processo nº 0092142-83.2023.8.17.2001

AUTOR(A): G. B. M.

REPRESENTANTE: NATACHA BEZERRA BRASILINO MAFRA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos etc.

GIOVANNA BRASILINO MAFRA, menor impúbere, representada por sua genitora **NATACHA BEZERRA BRASILINO MAFRA**, todos devidamente qualificados na peça vestibular, ajuizou **AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** contra a **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificado nos autos.

Narra a demandante, em breve resumo, que nasceu pequena para a idade gestacional, patologia conhecida pela sigla PIG (CID P05.1), que ocasiona a altura abaixo da média da população geral e o início da puberdade em idade antecipada, levando a um prejuízo ainda maior do seu crescimento, necessitando, com urgência, realizar tratamento mediante reposição do hormônio do crescimento **GENOTROPIN 12mg - 03 ampolas com aplicação de 0,9mg subcutâneo diariamente**; de modo contínuo, conforme laudo e receituário médicos de ID nº 141115902.

Aduz que, apesar de estar cumprindo com a sua parte na avença, a suplicada recusa-se a autorizar seu tratamento, sendo, tal atitude da ré, abusiva e atentatória contra as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e contra os seus direitos de consumidor.

Ante o relatado, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência antecipada, com o fito de determinar à demandada que autorize e custeie o fornecimento da medicação para seu tratamento. No mérito, pugna pela confirmação da tutela

requerida e pela condenação da ré no pagamento dos danos morais suportados, no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais no importe de R$ 1.459,80 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), referente a medicação adquirida em 25.07.2023.

A exordial veio provida de documentos instrutórios.

Custas antecipadas.

No despacho de Id. 141249508, este Juízo solicitou informações à Ré.

Regularmente citada a ré ofertou peça de bloqueio de id. 142615487, aduzindo que a negativa se deu em razão da inexistência de obrigação legal e contratual para o custeio do medicamento, tudo em razão da obrigação não constar no rol de procedimentos da ANS. Aduz, ainda, que inexiste dano moral indenizável. Ao final, pugna pela total improcedência do feito.

A peça de defesa veio acompanhada de documentos instrutórios.

Deferido o pedido de antecipação de tutela por meio da decisão de Id °143045388.

Devidamente intimado, o autor apresentou réplica de id. 143471335.

A ré apresentou petição comunicando a interposição de agravo de instrumento id. 146410157, NPU 0020099-06.2023.8.17.9000, Órgão julgador: Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho.

As partes mesmo intimadas, não manifestaram o desejo de produzir novas provas.

Manifestação do Ministério Público de id. 176363950, pugnando pela "**procedência** do pedido atrial para declarar a nulidade de qualquer cláusula abusiva no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, notadamente as que impeçam o tratamento do autor por exclusão do polo demandado, e, consequentemente reconhecer a responsabilidade contratual da empresa ré em fornecer todo o tratamento e medicamentos prescritos, possibilitando, assim a cobertura integral de todos os procedimentos e demais custos, pelo tempo necessário ao

tratamento do infante, conforme laudo médico que baliza o processo, além de **indenização** a título de **danos morais**, em *quantum* a ser decidido pelo juízo".

Após, volveram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a **DECIDIR:**

Ab initio, é de se frisar que, na hipótese, a produção de outros meios de prova se afigura desnecessária, isto porque os fatos narrados e os documentos colacionados pelas partes emergem suficientes para ensejar o pleno exame das questões postas, circunstância que, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Estatuto de Ritos, autoriza o julgamento antecipado da lide.

Acrescente-se, ainda, que mesmo intimados os interessados não pugnaram pela produção de novas provas, o que reforça o entendimento vigente quanto ao julgamento antecipado do mérito.

Feitas tais considerações, passo a analisar o mérito propriamente dito:

Como é cediço, com o advento da Lei nº 8.078/90 (CDC, Código de Defesa do Consumidor), surgiram novos conceitos, dentre eles o de relação de consumo, que é formada, de um lado, pelo consumidor, de outro, pelo fornecedor, e que possui, como objeto, uma prestação de serviço ou entrega de um produto.

Sem maiores dificuldades, conclui-se pela aplicabilidade à espécie das normas do referido diploma legislativo.

Nesse passo, vislumbro *in casu* a incidência específica da regra esculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Com efeito, a exceção ao ônus probatório, ali disciplinada, incide diante de duas hipóteses: (a) quando a alegação for verossímil; ou (b) quando o consumidor se demonstrar hipossuficiente.

Entende-se por "alegação verossímil" a presunção da veracidade de um fato abstraída pelo magistrado a partir de outro fato provado, em razão das regras ordinárias de experiência. Hipossuficiente, por sua vez, é a condição daquele que numa relação de consumo se encontra em posição de inferioridade em face do fornecedor, seja porque não dispõe de recursos econômicos, seja porque não detém o controle dos mecanismos de produção dos bens ou serviços.

Na hipótese dos autos, enxergo caracterizadas ambas as situações contempladas na lei, de forma a autorizar a alegada inversão do *onus probandi*, afastando-se a regra geral no que se refere ao ônus da prova.

Firmada a distribuição do ônus da prova no presente caso, não se pode olvidar que à requerida competia demonstrar que a negativa operacionalizada era devida.

Ocorre que, mesmo diante da imposição legal de comprovar que a negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico foi legítima, a empresa ré nada comprovou, restringindo-se apenas a formular alegações sem, contudo, provar nenhum fato modificativo, impeditivo ou mesmo extintivo do direito do autor.

É incontroverso que o demandante apresentava a enfermidade descrita no exordial, necessitando, por consequência, do tratamento prescrito, com a utilização dos meios e materiais descritos por seu médico, com vistas a maximizar as possibilidades de êxito, tudo em absoluta consonância com o laudo médico apresentado.

Por seu turno, a ré afirma, em sua contestação, que o tratamento sonegado não tem previsão no contrato firmado e no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e que por isso a negativa seria devida.

Primeiramente, a empresa prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar não pode interferir na indicação de tratamento feita pelo profissional de saúde, tendo em vista que o médico, ao acompanhar o paciente, estando a par de seu diagnóstico e condições, é o mais apto a eleger o tratamento de melhor adequação ao restabelecimento por completo de sua saúde.

Nesse sentido, trago o precedente abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADOLESCENTE PORTADOR DE BAIXA ESTATURA. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO HORMONAL (SOMATROPINA). REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. - O contrato de plano de saúde se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente aos princípios da boa-fé, da confiança e da vulnerabilidade, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e redigidas com destaque quando implicarem limitação de direitos. 2. No caso, foi demonstrado por meio de laudo médico, a necessidade do fornecimento de SOMATROPINA, sendo imprescindível para o sucesso do tratamento de menor de baixa estatura. 3. O medicamento é registrado pela ANVISA, de modo que a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento. 4. Decisão agravada mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 0000590-26.2022.8.17.9000, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, Juiz José Raimundo dos Santos Costa, Desembargador Substituto, tudo na conformidade das notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife/PE, data da assinatura digital. JUIZ JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA Desembargador Substituto 07 (TJ-PE - AI: 00005902620228179000, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

É importante frisarmos que o contrato celebrado com a parte é de proteção integral à saúde e à vida e não pode a ré se imiscuir na seara médica, fazendo a prévia exclusão de alguns tratamentos, vez que, como dito acima, o contrato visa a proteção integral à saúde.

Acrescente-se que mesmo antes da edição da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, esse juízo já comungava do entendimento de que o Rol de Procedimentos da ANS seria meramente exemplificativo, não se exaurindo na lista em referência, pois o plano de saúde não poderia ficar restrito simplesmente às disposições da Lei 9.656/98 e ao Rol de Procedimentos da ANS, já que o contrato celebrado com a parte é de proteção integral à saúde e à vida.

É importante frisarmos que após a publicação da Lei nº 14.454/2022 esse debate perdeu sua razão de ser, pois a citada lei pacificou os debates existentes nos seguintes termos:

> *Art. 10. (...)*
>
> *§ 4º - A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.*
>
> *(...)*
>
> *§ 12 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,* ***constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde*** *contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*

Aqui, para além dos dispositivos legais acima referidos, deve-se observar, especialmente, os princípios da dignidade da pessoa humana, não podendo a seguradora se recusar a autorizar os tratamentos necessitados pelo paciente, quando a sua ausência importar sequelas irreversíveis ao enfermo.

Assim, a meu ver, é ilegítima e abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da forma como foi prescrito para o demandante, pois expressamente solicitado pelo médico que o acompanha, com o fito de maximizar a possibilidade de cura.

A justificativa levada a efeito pela ré baseia-se, tão somente, na ausência de previsão do tratamento no Rol de Coberturas Obrigatórias da ANS e na falta de previsão contratual, o que não procede.

Trago à colação precedente que se assemelha à discussão aqui travada:

> EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Nos casos de urgência e emergência, em que o risco à vida se revele presente, admite-se interpretação extensiva do art. 10, VI, da lei 9.656/98 – que exclui da cobertura assistencial mínima o fornecimento de medicamento para tratamento

> domiciliar - para abranger o medicamento ministrado por orientação do médico assistente fora do regime de internação hospitalar, levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e a sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante. 2. Hipótese em que o tratamento medicamentoso pleiteado não se apresenta como terapia fundamental para a vida do paciente, mormente porque o laudo do médico assistente justifica a urgência do início do tratamento com o hormônio do crescimento tão somente no fato de a menor ficar com "altura final muito abaixo do padrão populacional feminino e genético". 3. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 0000272-59.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. (TJ-PE - AC: 00002725920208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Assim, havendo cobertura da doença da parte autora, o plano não pode excluir o tipo de tratamento utilizado e mais adequado para a sua respectiva cura. Havendo previsão de exclusão do tratamento, cuja doença a que se relaciona encontra cobertura, a cláusula contratual correspondente é abusiva, não podendo vigorar.

Assim, por todo o embasamento aqui feito, entendo abusiva e ilícita a recusa ofertada pela ré, que deveria ter orientado sua conduta para a cobertura do medicamento pretendido pelo paciente ora demandante.

A ratificação da tutela antecipada concedida não vem a ser, apenas, medida de justiça, mas também, e principalmente, uma providência necessária à manutenção da vida, que é certamente o objetivo único pelo qual a parte autora associou-se à entidade demandada.

DOS DANOS MORAIS

Pretende, também, a parte autora ser ressarcida por danos morais que a conduta dita abusiva lhe teria sido causada pela parte ré.

De fato, o dano moral não reflete desfalque patrimonial, mas qualquer atentado à tranquilidade, às expectativas intimamente construídas em razão de contratos celebrados, materializando-se, *in casu*, na injusta recusa no cumprimento do contrato de assistência à saúde há muito celebrado.

Em sintonia com tal tese, o Tribunal de Justiça de Pernambuco pacificou entendimento de que: **a negativa de cobertura fundada em cláusula de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral**. (Súmula 35).

Nesse diapasão, não prospera a tentativa da ré de desqualificar a sua incúria e desleixo como insuscetíveis de causarem constrangimento reparável. A série de circunstâncias que desencadearam a ofensa íntima e subjetiva anunciada pela requerente quedou corroborada pelo conjunto probatório produzido.

A vexatória e indevida negativa de autorização de procedimento, sem causa legal ou fática que a legitime, constitui abuso de direito que se enquadra no enunciado do artigo 186, do Código Civil e por isso é ato ilícito, provocador de reparação pecuniária através dos critérios compensatórios e sancionatórios, visando a recomposição do patrimônio moral aviltado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensações outras, capazes de retribuir-lhe satisfações e alegrias na justa medida do abalo sofrido.

Para fixação do valor da indenização a ser arbitrada a título de dano moral, faz-se impositiva a aplicação da **TEORIA DO DESESTÍMULO**, que visa a estipulação de um valor indenizatório justo, o qual, constitua, simultaneamente, óbice à perpetuação da conduta reprovável pelo causador do dano e funcione como uma atenuação à moral do ofendido; já que a mesma não é passível de quantificação monetária. Assim, busca-se um equilíbrio perfeito de forma que não onere excessivamente quem dá, nem enriqueça ilicitamente quem recebe.

A par das referidas considerações, arbitro em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, o quantum indenizatório a ser suportado pela parte ré.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao pedido de reembolso, entendo que tal sorte logrou a parte autora, uma vez que, conforme se observa no laudo médico anexado, o tratamento foi solicitado considerando o quadro da segurada.

Dessa forma, comprovado a necessidade para a realização de procedimento, nos termos do art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e verificado nos autos a comprovação do pagamento faz jus o autor ao reembolso, conforme nota fiscal id.141115909.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o que consta nos autos, levando-se em consideração a manifestação ministerial favorável, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo **JULGAR PROCEDENTES** as pretensões entabuladas na exordial, para:

a) **CONDENAR** a parte requerida ao pagamento de **R$ 1.459,80 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)** a requerente, para reparar os **danos materiais sofridos**, valor este a ser atualizado monetariamente de acordo com a Tabela ENCOGE desde o desembolso, sendo devidos também juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

b) DETERMINAR que a Réu **autorize e custei o tratamento da parte autora nos termos prescritos pelo médico**, qual seja, forneça o medicamento **GENOTROPIN 12MG**, na quantidade exigida no Laudo e Guia Médico, podendo aumentar a dosagem de acordo com a prescrição médica, pelo tempo que for necessário, ao mesmo tempo em que confirmo a **TUTELA** concedida antecipadamente para os efeitos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC;

c) **CONDENAR** a ré ao pagamento de indenização por dano moral, na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização pela tabela ENCOGE a partir desta Sentença (Súmula 362 STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade, **condeno** a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação com arrimo no Art.85, § 2º, I e IV do CPC.

Oficie-se o Desembargador Relator Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho nos autos do agravo 0020099-06.2023.8.17.9000 informando quanto ao julgamento do feito.

No caso de interposição de apelação, determino a intimação da apelada para responder no prazo legal de 15(quinze) dias úteis e posteriormente decorrido esse prazo com ou sem resposta, encaminhe-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça e/ou no caso do trânsito em julgado da sentença, aguarde-se o decurso do prazo de 15(quinze) dias úteis para promoção do pedido de cumprimento de sentença ou o cumprimento espontâneo, arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais.

Alerto às partes que, ao opor-se a decisão deste juízo, atente às peculiaridades do feito e aos princípios processuais, pois a adoção de embargos de declaração com intuito protelatório poderá acarretar na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

P.R.I. e com o trânsito em julgado e decorrido o prazo acima assinalado para ajuizamento do cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Recife, data da assinatura.

Fernando Jorge Ribeiro Raposo

Juiz de Direito

R

Assinado eletronicamente por: FERNANDO JORGE RIBEIRO RAPOSO
03/09/2024 10:01:54
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 180506567

24090310015393800000176123696

IMPRIMIR GERAR PDF